

1502434-55.2021.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... levado ao DP. Já foi processado por tráfico, forjado também. Não sabe pilotar carro, e era o rapaz do bar que colocava o carro que lavava em outro lugar. No dia e hora do crime estava trabalhando no lava rápido. Era uma sexta-feira, dia que mais roda, assim como sábado, e às vezes ficava até 22:00 horas. Seu pagamento era feito em dinheiro, cerca de trezentos e cinquenta. Tinha conta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502434-55.2021.8.26.0161 - Controle nº 2021/001252

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2235969/2021 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 3 e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

WELLINGTON MESQUITA DE FREITAS, qualificado indiretamente às fls. 49/50 e 76/79, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 155, §4º-B, na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 19h25, na Rua Brás Cubas, altura do nº 120, bairro Casa Grande, nesta Comarca, atuando previamente ajustado outros dois indivíduos não identificados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Nedison Vicente de Jesus, subtraiu, para eles, o veículo Toyota/Yaris, de placas GKD/7F15, dois telefones celulares das marcas Samsung J5 e Samsung J7, uma máquina de cartão de crédito, uma aliança de ouro e a quantia de R\$ 350,00 em espécie. Consta ainda que, após os fatos supranarrados, nesta Comarca de Diadema, o acusado, atuando previamente ajustado outros dois indivíduos não identificados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o

fim comum, subtraiu, para ele, mediante fraude por invasão de dispositivos eletrônicos, com ou sem a violação de mecanismo de segurança, a quantia total de R\$ 2.129,00 pertencente a vítima Nedison Vicente de Jesus, pleiteando por isso, o ressarcimento do montante de R\$ 7.679,00.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 98/99). A denúncia foi recebida em 07/02/2022 (fls. 98/99). Citado (fl. 76), foi nomeado Defensoria Pública que apresentou a sua defesa inicial às fls. 160/161.

Em audiência inicial, foi ouvida a vítima, tendo a d. Defensora Pública insistido na oitiva das testemunhas de defesa, juntando novo endereço, sendo elas ouvidas em audiência em continuação, e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução processual, à pedido das Partes, concedeu-se prazo para juntada de memoriais. Nestes (fls. 211/217), o d. Representante do Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provada autoria e materialidade delitiva. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o aumento pela reincidência do agente além do duplo aumento pela presença de duas majorantes, somando-se as penas dos dois delitos, sem aplicação do disposto no art. 44 do CP, nem do recurso em liberdade, fixando-se regime prisional fechado, além da condenação ao pagamento do dano patrimonial à vítima.

Já a d. Defensora Pública pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento do crime de furto, por ser um desdobramento do roubo, afastando-se ainda a majorante do emprego de arma de fogo nesse último delito ante ausência de prova pericial, fixando-se a pena no mínimo legal, com aumento único ainda que sejam duas causas de aumento de pena, a ser cumprida em regime compatível com o tempo de prisão por esse processo, cinco meses, e a possibilidade do acusado recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

Quanto à alegação de ilegalidade do reconhecimento na fase policial, feito por fotografia única do réu, afasto tal tese, pois a vítima já havia descrito os meliantes, informando cor da pele, altura, compleição física, idade aproximada, e até que um deles tinha olhos claros, não se podendo alegar que tais características sejam aleatórias ou genéricas, pelo contrário, foi bem específico. Ademais, o artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações a serem seguidas.

Nestes termos: Audiência realizada por videoconferência, justificada a medida nos termos do artigo 185, § 2º, do CPP e em razão da atual situação de pandemia.

Prejuízo não demonstrado. Acusado reconhecido pela vítima nas duas fases da persecução de forma segura. Inteligência do artigo 226 do Código de Processo Penal. Dispositivo que traz mera recomendação no sentido de ser o réu colocado ao lado de outras pessoas quando da realização do ato, algo diverso de obrigatoriedade. Tese da Defesa há muito desgastada, a par de contrária à pacífica jurisprudência.

Precedentes.”(Apelação Criminal nº 1501951-98.2020.8.26.0536, São Vicente, rel.

Farto Salles, j. 03/02/2022). Cito ainda: “[...]em tema de reconhecimento, o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepor-la ao próprio conteúdo. (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT 730).

Tanto que em sede judicial, como veremos na sequência, a vítima reconheceu o réu pessoalmente, contando com a concordância da própria Defesa que ele não estivesse acompanhado de outros indivíduos que com ele guardasse semelhança, não cabendo, portanto, ao d. Defensor Público alegar nulidade à qual também deu causa, não sendo honesta tal conduta, data venia.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 42/46, auto de reconhecimento pessoal fotográfico de fl. 61, auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 40), certidão de avaliação de fls. 93, e comprovantes de transferências bancárias às fls. 56/57.

Ressalto que: Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório. (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas BMJ 91/6 e RDJ 18/66)

A autoria é inconteste.

A vítima Nedison Vicente de Jesus, ouvida em solo policial (fls. 58/59), declarou que trabalha como motorista de aplicativo e na data dos fatos estava dirigindo seu veículo Toyota Yaris, e ao deixar a passageira nas imediações da Rua Brás Cubas, foi subitamente abordado por três indivíduos, que vieram na parte frontal do veículo, cada um com uma arma de fogo, aparentando serem dois revólveres pretos e um revólver cromado. Na sequência, um dos roubadores já seguiu para a porta da vítima gritando: destrava a porta senão eu atiro (sic), apontando o revólver cromado, sendo que os outros dois roubadores tomaram assentos dentro do veículo (um no banco do passageiro dianteiro e outro no assento traseiro). Visualizou claramente o roubador que entrou pela sua porta, embora fosse noite, e era um indivíduo branco, magro, idade entre 20 e 25 anos aproximadamente, olhos claros, altura por volta de 1,75m. Os outros dois agentes também eram brancos, com idade próxima ao do primeiro roubador descrito, porém, como voltou suas atenções para o acusado que entrou pela sua porta, não prestou tanta atenção neles. Foram roubados dois celulares, um Samsung Galaxy Prime 5 e um Galaxy Prime 7, R\$ 350,00 em espécie, além da aliança de ouro. Posteriormente, quando comprou um novo aparelho e habilitou a linha, verificou que haviam sido feitas duas transações a partir de sua conta no Mercado Pago, uma de R\$ 219,00 e outra de R\$ 2.000,00, ambas realizadas para Wellington Mesquita de Freitas, e o reconheceu como sendo o roubador que veio pela sua porta, com o revolver em riste, anunciando o assalto, levando seus itens e depois realizando as transferências bancárias.

Neste sentido foram as declarações da vítima em solo judicial reiterando que tinha acabado de deixar uma passageira e foi abordado por eles, que vieram apontando a arma, mandando descer do carro, pegando sua aliança, e celular, fazendo PIX para eles, saindo com o carro em fuga. Eram três rapazes, todos eles armados, eram três armas, e o que transferiu o dinheiro para ele, foi o que apontou a arma para si. E depois os outros dois vieram nas laterais também apontando as armas. Ligou para a polícia. Foi tudo muito rápido. Recuperou o carro apenas, mas não também a aliança de casamento, nem o valor do PIX, nem a máquina de cartão e os dois aparelhos celulares. Sofreu um prejuízo de uns sete mil reais. O réu era o mais agressivo e quem pegou sua aliança e fez o PIX. Mostraram a foto do réu ao puxarem o CPF dele e o reconheceu na hora. Esse meliante era branco, quase da sua altura, e devia ter uns vinte e poucos anos, é novo. Nessa audiência reconheceu o acusado, era o mais agressivo, pôs a arma na sua cabeça, puxou sua aliança que até doeu, gritava: perdeu, perdeu! Reconhece também a fotografia juntada aos autos a fl.58, que lhe foi mostrada no DP e assim reconheceu o réu. Não entende de arma, mas acha que a que lhe foi apontada pelo réu parecia uma "38", parecia prateada porque brilhava. A transferência se deu depois, pois foi obrigado a abrir a tela do banco e dar a senha. Só soube os valores transferidos depois, quando foi fazer o BO. Os outros dois meliastes estavam de capuz e focou mais no réu porque foi ele quem lhe abordou. Ele primeiro estava com touca, mas ao puxar sua aliança, o capuz caiu.

Em juízo perante ao Juiz imparcial, a testemunha de defesa Mateus Vital disse que desconhece os fatos. O réu trabalhava consigo desde 2020 lavando carros na sua garagem. Combinaram dele chegar cedo, por volta das 08:00 horas, de acordo com a hora que o réu acordasse, e ficavam até tarde, pois chegavam carros até umas 17:00 horas. Ficavam até escurecer, umas 19:00/20:00 horas e nos finais de semana, às vezes, até mais tarde se precisasse. Sabe que o réu fumava cigarro, mas desconhece se ele já tinha passagem policial. O réu trabalhou consigo até ele ser preso nesse ano, o réu trabalhou consigo até uns três ou quatro meses atrás.

A testemunha de defesa Noemi Vital, em sede judicial declarou que desconhece os fatos. Conhece o réu, que trabalhava na padaria próxima, e em 2020 ele ajudava na pandemia lavando carros. Ele chegava entre 08:00/09:00 horas e saía por volta das 19:00/20:00 horas. Não lembra se o réu estava trabalhando no dia da prisão.

Acredita que o réu trabalhou consigo até abril ou maio desse ano. Mateus é seu filho e trabalhavam juntos. O acusado trabalhava informalmente, não tinha carteira registrada nem horário de ponto. O horário de trabalho variava de acordo com a entrada de carros, e ainda estivessem na pandemia, chegavam carros para lavar, e eles ficavam esperando.

O indiciado não apresentou sua versão em sede policial. E sob o crivo do contraditório, o réu alegou que trabalhava e que não tem nada a ver com o crime, o negando. Estava andando na rua e foi enquadrado. Os policiais disseram que estava devendo uns dias, e foi levado ao DP. Já foi processado por tráfico, forjado também. Não sabe pilotar carro, e era o rapaz do bar que colocava o carro que lavava em outro lugar. No dia e hora do crime estava trabalhando no lava rápido. Era uma sexta-feira, dia que mais roda, assim como sábado, e às vezes ficava até 22:00 horas. Seu pagamento era feito em dinheiro, cerca de trezentos e cinquenta. Tinha conta bancária, no banco Aixa. No dia dos fatos, por volta das (155/57) recebeu PIX vindo da conta da vítima do roubo e não sabe explicar o motivo da transferência. Não conhece compra feita no Mercado Pago.

Em conclusão, não me restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, especialmente pelas declarações das vítimas, quer pelo reconhecimento pessoal positivo feito por ela em ambas as fases da persecução penal, bem como pela prova documental através dos comprovantes de transferências de valores em favor do acusado, em seu CPF e conta bancária, tudo sem prova contrária, de modo que a procedência do pedido é inarredável, até porque as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos e em nada contribuíram à elucidação do roubo, trazendo manifestação genérica no sentido de que o réu trabalhava esporádica e informalmente, num lava rápido, trazendo também de forma genérica os dias e horários de trabalho, também oscilante conforme a procura, e sem saberem precisar se no dia e hora do crime ele estaria, efetivamente, no lava rápido, até porque não há cartão de ponto nem prova de que foram lavados muitos carros a ponto do réu ter que ficar no trabalho até tarde, prova esta que competia à Defesa, já que quem alega.

Assim como a prova de que o réu "teria sido vítima de abertura fraudulenta de conta bancária em seu nome e que não seria ele o real destinatário" dos valores dos PIX feitos ao seu CPF. Ora, tal prova também seria da Defesa, quem alega e, portanto, tem esse ônus nos termos do art. 156 do CPP.

Portanto, no que tange aos crimes apontados ao réu, perscrutando os depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima, todos foram harmônicos ao apresentarem a dinâmica dos fatos ocorridos, o modus operandi do acusado, a forma como foi a abordagem, sob grave ameaça sofrida mediante apresentação de três armas de fogo por três meliantes diferentes, subjugando-a e reduzindo qualquer esfera de defesa de sua vida e de seu patrimônio.

A declaração da vítima deve ser prestigiada pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições. E no caso dos autos, a palavra do ofendido revelou-se plenamente verossímil, corroborada com os demais elementos probatórios. Ressalto que: em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria ela qualquer proveito em mentir. (TJSP - Apelação Criminal nº 1500517-62.2019.8.26.0616, Relator Desembargador Alcides Malossi Júnior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.08.2021).

O concurso de agentes ficou devidamente esquadrinhado através da palavra do ofendido, demonstrando claramente a ação dos três agentes conluiados para a prática da conduta delituosa, ante a clara divisão de tarefas, cercando o carro, cada qual com uma arma em riste, dificultando a reação, causando maior temor dado à desvantagem do número de pessoas e quantidade excessiva de armas, prejudicando qualquer hipótese de evasão do ofendido, colaborando à pronta consumação do crime e êxito na fuga.

No tocante à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, a prova oral colhida em Juízo é suficiente para demonstrar que a ameaça foi exercida com emprego de mais de uma delas, sem prova contrária. E ainda não tenha sido o objeto apreendido nem periciado, deve ser considerado a majorar a pena ante a conduta do

rêu em se armar para assim facilitar a ação, de modo que deve ser considerado em seu desfavor. Neste sentido: A falta de apreensão da arma não acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, § 2º, I, do C.P., pois a circunstância pode ser suprida por outro meio de prova, testemunhal inclusive (TACRIM-SPAC- Rel. Exmo. Juiz HAROLDO LUZ - RT 680/362).

Ainda, colaciono os seguintes precedentes do E. STF:

"HABEAS CORPUS. ART. 157 §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ARMA NÃO APREENDIDA. PRESCINDÍVEL APREENSÃO DA ARMA. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO. PRECEDENTE CITADO. 1. A qualificadora de uso de arma de fogo independe da apreensão da arma, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância. 2. Ordem denegada." (STF - HC 92.451/SP - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 09.09.2008 - DJU 06.02.2009 - grifei);

E: "ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra 'in re ipsa'. III - A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida." (STF - HC 96.099/RS - 1ª T. (TRIBUNAL PLENO) - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 04.11.2008 - DJU 05.06.2009 - grifei) .

No tocante ao crime de furto qualificado, em análise aos elementos coligidos, incontestemente a conduta perpetrada, pois houve a subtração dos valores da conta corrente do ofendido, conforme se observa pelos comprovantes de transferência juntados às fls. 56/57, destacando que não houve ao menos um zelo pelo furtador para tentar dificultar o destinatário, creditando os valores para si próprio, sem prova inclusive de que tais valores tenham sido transferidos, logo após, à terceira pessoa a indicar que, eventualmente, como pretende a Defesa, "o réu não fosse o destinatário real".

Denota-se que na utilização do aparelho celular roubado, com o pleno acesso ao sistema informatizado bancário e assim ludibriando o sistema de segurança por não ser o correntista, houve a subtração de valores da conta corrente da vítima, num segundo momento, mediante transferência fraudulenta de numerário mantido sob guarda bancária, sem consentimento da vítima, configurando assim o crime de furto mediante fraude. E não mero "desdobramento" do primeiro crime, nem mero "exaurimento do roubo", pois já em poder dos bens materiais/físicos (celular, aliança e dinheiro) e não satisfeito com o produto do ilícito, o réu, num segundo momento, já estando o roubo consumado, tanto que já em poder do aparelho celular através do qual fez uso da conta bancária da vítima, e passou DOIS PIXs.

Nesse sentido também é o entendimento da Corte Superior:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA INTERNET SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DA AGÊNCIA ONDE O CORRENTISTA POSSUI A CONTA FRAUDADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a subtração de valores de conta corrente, mediante transferência fraudulenta, utilizada para ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores, mantidos sob guarda bancária, sem consentimento da vítima, configura crime de furto mediante fraude, previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal - CP. 2. O delito em questão consuma-se no local da agência bancária onde o

correntista fraudado possui a conta, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal - CPP; no caso, na Comarca de Barueri/SP. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barueri/SP, o suscitado. (CC 145.576/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 20/04/2016 - grifei). E atualmente já existe tipificação própria para o delito de furto eletrônico dado à grande ocorrência dele na era da informática.

Malgrado a aludida versão exculpatória do réu, desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxe qualquer álibi que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.

O arcabouço fático-probatório amealhado é capaz de afirmar de maneira inequívoca a responsabilidade criminal do réu, de forma que não se há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Destarte, dos elementos ponderados evidenciou-se que o réu praticou crime de roubo, agravado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma consumada, e depois, ainda, num segundo momento, e sem nexos causal nem contingência, praticou o furto eletrônico, também consujado. Portanto, de rigor sua condenação pelos dois delitos, em concurso material de crimes.

Não se pode falar em continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto por serem infrações penais de espécies diferentes e que tem definição legal autônoma, e não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes (Precedentes - HC/MS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 5º Turma - DJE 25/11/2019).

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, especialmente as consequências do crime, pelo alto prejuízo patrimonial à vítima, quem ficou sem seus aparelhos celulares, inclusive para seu trabalho com aplicativo Uber, e sem sua aliança de casamento, de notório valor sentimental, além dos valores subtraídos, em ocasião diversa, a segunda delas em valor altíssimo, tudo a demonstrar maior audácia e avareza do agente. Sobre o acréscimo efetuado nessa etapa, a propósito, conforme já reconheceu o Pretório Excelso, a importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), fixo em primeira fase as penas base acima dos mínimos legais, ou seja, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa para o crime de roubo e 05 anos de reclusão e 12 dias-multa para o delito de furto qualificado.

Arbitro cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira dos condenados.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes a se considera, mas presente a agravante da reincidência comprovada a fl. 218, a aumentar as penas em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão mais 14 dias-multa, por cada crime.

Em terceira fase, sem causas de redução de pena para nenhum crime, nem de aumento para o furto qualificado. Mas sim para o delito de roubo, e a aumento em 1/3 pela majorante do concurso de agentes, que na presente hipótese há de se considerar a presença desnecessária e excessiva de três meliantes, perfazendo 07 anos, 09 meses e 10 de reclusão e 18 dias-multa. A qual elevo em 2/3 pela causa de aumento do emprego de três armas de fogo, a gerar maior risco e demonstrar maior periculosidade do agente, sendo proporcional o aumento diante da maior gravidade da conduta, totalizando 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão mais 30 dias-multa.

Considereei estes dois aumentos para que as majorantes que antecedem topograficamente a do uso de arma de fogo não deixem de ser consideradas, e porque: ... com a nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº

13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2.º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a metade e, no § 2.º-A, I, majoração fixa em

2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo (...)" (TJSP. 4.^a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0062757-50.2018.8.26.0050, rel. CAMILO LÉLLIS, j. 30/04/2019, v.u.)- grifei.
Nos moldes do art. 69 do CP, somo as reprimendas que totalizam 18 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão mais 44 dias-multa.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a quantidade da pena de um lado e de outro, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a reincidência (fl. 95 e 128), fixo o regime prisional fechado. Ademais: O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada (JUTACRIMSP 91/117)grifei.

Finalmente, não há falar-se em estipulação imediata de regime menos severo, considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as circunstâncias já apontadas, que determinam o regime mais gravoso. Cabe lembrar que a detração do artigo 387, § 2º, do CPP, a teor do que vem decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva. O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33, § 2º, do Código Penal. No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI: Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando-se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime. A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2º, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que inclui o regime, de maneira correta. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.^a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 805/806).

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, porque o crime foi praticado com grave ameaça a pessoa e o quantum

da pena fixada ultrapassa o máximo permitido em lei, além de não ser suficiente nem eficaz à reprovação da conduta e prevenção dos crimes praticados, menos ainda socialmente recomendável à réu reincidente, pois ausente o requisito legal subjetivo, inclusive.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: (...)Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...)” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado mediante desde a data dos fatos, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juízo da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Ademais, a prisão perdura meros cinco meses, sem direito sequer à progressão de regime.

Este é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inseri dano § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração .Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Por fim, fixo valor de reparação do dano em R\$ 7.679,00, deduzindo os valores bloqueados conforme fls. 121/123 a serem disponibilizados para o ofendido, uma vez que restaram devidamente demonstrados documental e verbalmente os PIXs feitos, valor esse que já constou da denúncia e acerca do qual o réu e sua defesa tiveram o amplo contraditório, tudo sem prova contrária.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra WELLINGTON MESQUITA DE FREITAS, qualificado indiretamente às fls. 49/50 e 76/79, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 155, §4º-B, na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, e o faço para condenar à pena de 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento. Além do ressarcimento à vítima, a título de valor mínimo de reparação de dano, no montante de R\$ 7.679,00.

O réu não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere em que está. Expeça-se o necessário.

Sem condenação nas custas processuais ante assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da multa.

Comunique-se a vítima nos termos do art. 201, §2º do CPP.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.I.C.

Diadema, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA